

1502339-67.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... restou demonstrado que o réu faz do tráfico seu meio de vida, não possuindo ocupação lícita e foi preso no mesmo local no dia 05/04/2021 praticando o tráfico de drogas, além disso, o denunciado referiu que ao menos 4 vezes já havia estado naquele local. No que tange ao regime, requereu o inicial fechado, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502339-67.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502339-67.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR HENRIQUE CORDEIRO DE ALMEIDA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Vistos.

CESAR HENRIQUE CORDEIRO DE ALMEIDA DOS SANTOS, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 08 de Setembro de 2021, por volta das 20h00min, na rua Senador Robert Kennedy, altura do número 01, na via pública, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, teria trazido consigo 242 porções de "crack" (produto derivado da cocaína - peso líquido de 28,2g); 76 porções de cocaína (peso líquido de 39,6g); e 55 porções de maconha (peso líquido de 128,3g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para comercialização e entrega a terceiro, além da quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais) em notas trocadas (auto de exibição e apreensão - fls.06/07; laudo de constatação de fls. 09/11).

Conforme a denúncia (fls.44/45) e, segundo o apurado, o réu, em tese, resolveu realizar comércio ilícito em local conhecido como "ponto" de venda de drogas e, para isso, trazia consigo as drogas acima mencionadas, no interior de uma bolsa. Na ocasião, Policiais Civis trafegavam pelo local dos fatos e, teoricamente, visualizaram o réu em atitude suspeita, qual seja, verificaram o exato momento que o denunciado pegava objetos de dentro de uma bolsa e entregava a pessoas que por ali passavam mediante contraprestação em dinheiro. Na sequência, os policiais realizaram a abordagem e, durante busca pessoal, teriam localizado no interior da bolsa do réu 242 porções de "crack" (produto derivado da cocaína), 76 porções de cocaína e 55 porções de maconha. Assevera, a denúncia, que foi flagrado com

substâncias ilícitas em local conhecido como “ponto” de venda de drogas, especialmente embaladas, de diferentes qualidades e diversas quantidades, divididas de forma a permitir a imediata comercialização, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de drogas. O réu foi preso em flagrante às fls.01/02. Em solo policial, o réu confessou o crime (fls.14).

Termo de Audiência de Custódia às fls.26/30, oportunidade em que convertida a prisão em flagrante em preventiva, considerando a gravidade em concreto do fato delituoso, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais, com base nos artigos 282, § 6º, e artigos 310, inciso II e 312, todos do Código de Processo Penal. Mandado de Prisão fls.31/32.

Regularmente notificado (fls.61), o réu, por intermédio de advogado dativo, apresentou defesa prévia às fls.65/68, pugnando pelo benefício da justiça gratuita e pela concessão da liberdade provisória sem imposição de fiança; alternativamente, requereu a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares substitutivas à prisão; por fim, arrolou as mesmas testemunhas do órgão ministerial.

Decisão às fls.73 em que se manteve o decreto prisional.

Decisão às fls.76/77 em que recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento (fls.114/115), foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, interrogado o réu e mantido o decreto prisional.

Em alegações finais, o d. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia.

Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, opinou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a quantidade de drogas apreendidas e natureza nociva; na segunda fase, apontou a presença da atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, afastou o privilégio do artigo 33, §4º, da LD, pois restou demonstrado que o réu faz do tráfico seu meio de vida, não possuindo ocupação lícita e foi preso no mesmo local no dia 05/04/2021 praticando o tráfico de drogas, além disso, o denunciado referiu que ao menos 4 vezes já havia estado naquele local. No que tange ao regime, requereu o inicial fechado, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena.

A d. defesa, por sua vez, requereu a procedência da ação penal e teceu considerações acerca da dosimetria da pena, pugnando pelo reconhecimento da confissão na segunda fase e da aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo, na terceira fase. Ainda, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito do réu recorrer ao processo em liberdade.

Certidão de Antecedentes Criminais às fls.22/23 e Folha de Antecedentes às fls.20/21 e 98/100.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do mérito.

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01/02), Boletim de Ocorrência (fls.03/05), Auto de Exibição e Apreensão (fls.06/07), Laudo de Constatação de Entorpecente (cocaína - massa líquida: 39,6g e 28,2g; tetrahydrocannabinol - massa líquida: 128,3g - fls.09/11), Termo de Depoimento (fls.12/13), Termo de Interrogatório em Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls.14), Auto de Qualificação (fls.15), Nota de Culpa (fls.17), Laudo de Lesão Corporal Cautelar (fls.24/25), Relatório Final (fls.40/41), Depósito Judicial (fls.53), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (cocaína e tetrahydrocannabinol - fls.111/113), bem como pelas provas orais colhidas. Logo, é certo que restou devidamente comprovado o objeto material “droga”, indicado no tipo penal do caso vertente, que prevê crime não transeunte, sendo regularmente apreciados os seus vestígios em prova tarifada pelo legislador (artigo 158, do Código de Processo Penal c.c. artigo 50, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/06 - LD).

Sobreleva notar que tal substância encontra-se expressamente prevista na Portaria

344/98 e Resolução nº 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (artigo 1º, Sú., da LD).

De outra banda, verifico que a autoria restou delineada, ante a consonância dos elementos colhidos na fase inquisitorial com aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastasse, o réu, em seu interrogatório, confessou a prática do delito, e explanou que, no dia dos fatos, estava traficando; estava há pouco tempo no local, nunca havia realizado o tráfico antes; o policial lhe relatou que havia 274 porções de crack, 94 porções de cocaína e 54 porções de maconha; cada porção de crack, cocaína e maconha seria vendida por R\$ 5,00 (cinco reais); a droga era deixado pelos "meninos" (sic); não ficava sempre no local dos fatos, acredita que era a quarta vez; iria ganhar R\$ 200,00 (duzentos reais) ou R\$ 300,00 (trezentos reais); anteriormente, trabalhava em um mercado, depois passou a instalar ar-condicionado e, por último, trabalhou como cabeleireiro; fazia curso, todavia ficou sem dinheiro para pagar e foi influenciado a ingressar no tráfico; possui residência fixa, na rua Alfredo Carpi, Jardim Carpi; não reagiu no momento da abordagem; não possui contato com organização criminosa.

A par disso, a testemunha Phillipe Lacorte Ortiz, Policial Civil, em juízo, narrou que, o local dos fatos é conhecido por ocorrer o comércio de drogas; se dirigiram até o local para coibir; visualizaram o réu e então iniciaram uma campana, pois o local é próximo ao "escadão" (sic); aguardaram por alguns minutos e observaram que pessoas chegavam, entregavam algo para o réu e ele devolvia algo; acredita que visualizou a transação ocorrendo com duas pessoas; abordaram o réu; os terceiros se evadiram; o réu estava com uma bolsa que continha maconha, crack e cocaína, e uma quantia em dinheiro; conduziram o réu até a delegacia, momento em que o denunciado confessou que estava traficando; não conhecia o réu; se recorda que o réu foi preso pela Guarda em abril de 2021; o denunciado não demonstrou resistência.

Igualmente, a testemunha Rodrigo Izaac Leite Rosa, Policial Civil, declarou que, o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes; foram em diligência até o local; fizeram breve campana, sendo possível observarem que o réu estava nas imediações do "escadão" (sic), na posse de uma bolsa preta tiracolo; visualizaram que pessoas se aproximavam e entregavam algo ao réu, aparentando ser dinheiro, e o denunciado pegava algo da bolsa e entregava a pessoa; efetuaram a abordagem; dentro da bolsa havia 242 eppendorfs de crack, 55 porções de maconha, 76 porções de cocaína e a quantia em dinheiro trocado de R\$ 110,00 (cento e dez reais); o réu confessou a prática delitiva; conduziram o denunciado até a delegacia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência.

Ressalta-se que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 73518, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENTVOL-01846-02 PP-00293), o que, aliás, não se afere no caso em tela.

Como se vê, a prova é robusta o suficiente para embasar uma condenação, pois hialino que o réu praticou os núcleos "trazer consigo" e "vender", previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tipo misto alternativo, sendo certo que houve a apreensão de quantidade de droga suficiente para lesionar o bem jurídico tutelado, e já devidamente fracionada para venda, ainda mais porque não comprovou que exercia qualquer atividade remunerada à época dos fatos, donde se vê que sua conduta causou grande dano à saúde pública, além do fortalecimento de organizações paraestatais, violando o bem jurídico tutelado pela norma penal. De mais a mais, extrai-se o seu intuito comercial do próprio local em que concretizada a abordagem, qual seja, ponto de mercancia de drogas.

Incumbe salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu

ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, “o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT776/663). Logo, ainda nesta hipótese, restaria consumado o crime.

Por fim, nota-se que o acusado detinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Em observância ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e é adotado pelo Código Penal no artigo 68, passo à dosimetria da pena, anotando, desde já, a primariedade do agente.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atenta aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal e ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, observo que diante da natureza distinta entre os entorpecentes, potencial lesivo e a quantidade da substância em sua posse, a pena deve ser exasperada em 1/8. Destarte, fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 562 dias-multa.

De outro lado, incide a atenuante da confissão, utilizada para a formação do convencimento desta magistrada, imperiosa a incidência do disposto no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Assim, reduzo a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, é certo que “o crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. (...) Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017) e, no caso em tela, não há elementos suficientes a indicar que o réu se dedicava a atividades criminosas, ausente qualquer antecedente em sua folha de antecedentes nos autos. Assim, reduzo a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

O regime inicial será o semiaberto, em exegese ao artigo 33, do Código Penal. Ante o “quantum” da pena, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, e por tudo o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CESAR HENRIQUE CORDEIRO DE ALMEIDA DOS SANTOS à pena de 2 anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, “caput”, e parágrafos, do Código Penal), por restar incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva (artigo 312, do Código de Processo Penal), já que o recolhimento ao cárcere se mostra necessário para resguardar a ordem pública, ante o desassossego social causado pelo crime cometido pelo acusado. Além disso, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revela insuficiente para impedir a repetição da conduta delitiva.

Ainda, atendendo a nova redação do artigo 387, § 2º, Código Processual Penal, dada pela Lei 12.736/12, deixo de proceder à detração da pena, ante a inconstitucionalidade do dispositivo, por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético

de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe esta magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

Custas e demais despesas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (artigo 804, do Código Processual Penal).

Como a quantia apreendida e o bem apreendido estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva - fruto da mercancia da droga-, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (artigo 72, da LD).

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Expeça-se guia de execução penal.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C., Mairiporã, 30 de Março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA